

次の【事例】及び【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものを2個選びなさい。

【事例】

Xが甲に暴行を加えていたところにXの知人Yが通り掛かり、XとYが意思を通じ合った上で、その場で更に両名で甲に暴行を加えた。これらの暴行によって甲は傷害を負ったが、X及びYのどの暴行で傷害を負ったのかは不明であった。

【見 解】

本件では、Y加担前のXの暴行で甲に傷害が生じていた場合、YのXとの共謀やそれに基づく行為と甲の傷害との間に因果関係がない以上、X及びYに傷害罪の承継的共同正犯は成立しない。一般に、傷害の結果が、全く意思の連絡がない2名以上の者の同一機会における各暴行によって生じたことは明らかであるが、いずれの暴行によって生じたものであるかは確定することができない場合には、同時犯の特例として刑法第207条により傷害罪の共同正犯として処断される。また、共謀成立前後にわたる一連の暴行により傷害の結果が発生したことが明らかであるが、共謀成立前後のいずれの暴行により生じたものであるか確定することができない場合にも、一連の暴行が同一機会に行われたものである限り、刑法第207条が適用され、全体が傷害罪の共同正犯として処断されると解するのが相当である。X及びYは、傷害の結果につき同時傷害が成立し、全体につき傷害罪の共同正犯として処断すべきである。ただし、このような場合でも、単独犯の暴行によって傷害が生じたのか、共同正犯の暴行によって傷害が生じたのか不明であるという点で、やはりその傷害を生じさせた者を知ることができないときに当たることには変わりはないと解されるからである。

【記 述】

1. 【見解】の考え方によれば、本件でY加担前のXの暴行以前にX Y間の共謀が成立していたとしても、刑法第207条の適用がなければ、X及びYを傷害罪の共同正犯として処罰することはできない。
2. 【見解】の考え方によれば、仮に本件で刑法第207条が適用されない場合には、X及びYのいずれも暴行罪の共同正犯として処罰することになる。
3. 【見解】に対しては、「刑法第207条は、被害者が傷害を負っているにもかかわらず、誰にも傷害罪の責任を問えないことの不合理性を回避するための例外的な規定と考えるべきである。」との批判が可能である。
4. 【見解】に対しては、「仮に本件でX Y間に意思の疎通が一切なかった場合には刑法第207条が適用されてX及びYを傷害罪で処罰することとの均衡を失する。」との批判が可能である。
5. 【見解】の考え方によれば、仮に本件の甲の傷害がY加担前のXの暴行か、Y加担後のXの暴行によって生じたことが明らかであるが、そのいずれであるかが不明という場合には、X及びYを刑法第207条の適用により傷害罪の共同正犯として処罰することができる。

No154	共同正犯の成否	正答率
予備H26-13	正解 3. 5 (順不同)	31%

1 誤っている

【見解】は、「Y加担前のXの暴行で甲に傷害が生じていた場合」及び「共謀成立前後にわたる一連の暴行により傷害の結果が発生したことが明らかであるが、共謀成立前後のいずれの暴行により生じたものであるか確定することができない場合」について論じるものであり、「Y加担前のXの暴行以前にX Y間の共謀が成立していた」場合について直接論じるものではない。もっとも、「本件でY加担前のXの暴行以前にX Y間の共謀が成立していた」場合には、X Y間の共謀やそれに基づく行為と甲の傷害との間に因果関係が認められることから、【見解】によっても、207条の適用がなくても、X及びYを傷害罪の共同正犯として処罰することが可能である。

2 誤っている ★

【見解】の考え方によれば、仮に本件で207条の適用がないとした場合、Yに関しては、甲の傷害がY加担前のXの暴行により生じていた可能性がある以上、YのXとの共謀やそれに基づく行為と甲の傷害との間の因果関係が否定され、Yに甲の傷害結果を帰責することはできず、Yは暴行罪の共同正犯で処罰されるに止まる。他方、Xに関しては、甲の傷害は、Y加担前のXの暴行（傷害罪の単独犯）又はYとの共謀やそれに基づく行為（傷害罪の共同正犯）のいずれかによって生じたものであり、いずれの場合であっても、Xに甲の傷害結果を帰責することができる。そして、Xは、傷害罪の共同正犯、又は暴行罪の共同正犯と傷害罪の単独犯として処罰されることになる。

3 正しい

【見解】は、本件事例につき207条の適用を認める。他方、207条を「誰にも傷害罪の責任を問えないことの不合理性を回避するための例外的な規定」と考えた場合、207条の適用を否定してもXに傷害罪の成立を認めることができる本件事例では、その適用を否定すべきであると【見解】に対し批判が可能である。

4 誤っている

【見解】は、本件事例につき、207条の適用を認め、X及びYに傷害罪の共同正犯を認める。よって、X Y間に意思の疎通が一切なかった場合に207条が適用され、X及びYを傷害罪で処罰することとの均衡を失するものではない。

5 正しい

本記述にいう「本件の甲の傷害がY加担前のXの暴行か、Y加担後のXの暴行によって生じたことが明らかであるが、そのいずれであるか不明という場合」は、「共謀成立前後にわたる一連の暴行により傷害の結果が発生したことが明らかであるが、共謀成立前後のいずれの暴行により生じたものであるか確定することができない場合」に含まれる。【見解】の考えによれば、このような場合は「刑法第207条が適用され、全体が傷害罪の共同正犯として処断される」ことになる。